

1500511-52.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500511-52.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500511-52.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERALDO APARECIDO DE SALES FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EVERALDO APARECIDO DE SALES FREITAS, qualificado à fl. 27, imputando-lhe a prática do crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"1. Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Wilian Edi Tedros, nº 191, Jardim Alexandrina, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo, tinha em depósito e guardava droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente consistente em Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, nas seguintes medidas: (i) 01 (uma) porção com peso líquido aproximado de 50,6g (cinquenta gramas e sessenta centigramas - lacre nº 0036612); (ii) 11 (onze) porções com peso líquido total aproximado de 772,41g (setecentos e setenta e dois gramas e quarenta e um centigramas - lacre nº 0036613); (iii) 04 (quatro) porções com peso líquido total aproximado de 2.701,78g (dois mil, setecentos e um gramas e setenta e oito centigramas - lacre nº 0036614), sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar. 2. Consta do incluso auto, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado forneceu droga a Renato Ricardo de Melo, consistente em 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado de 23,5g (vinte e três gramas e cinquenta centigramas – lacre nº 0036611), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme boletim de ocorrência de fls. 43/49, autos de exibição e apreensão de fls. 52/53 e 75, fotografias de fls. 54/57, laudo de constatação de fls. 60/63, laudos periciais dos objetos apreendidos às fls. 162/164 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 165/168. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de droga acima descritas de terceira pessoa até o momento não identificada, guardou e deixou em depósito em sua residência e no terreno onde realizava reciclagem de materiais a maior parte das porções, bem como trouxe porções consigo, das quais uma forneceu a Renato Ricardo de Melo, para fins de tráfico. Inicialmente, cumpre registrar que os policiais militares receberam denúncia anônima noticiando que EVERALDO, que exerce atividades de reciclagem, tem traficado drogas “no peso”, ou seja, em grande quantidade, e que guardava a maior parte da substância entorpecente no matagal ao lado de sua casa. No dia dos fatos, policiais militares dirigiram-se ao imóvel visado e depararam-se com Renato Ricardo de Melo saindo do local com algo semelhante à droga em mãos, o qual arremessou para dentro do seu veículo Kadett. Abordado pelos policiais, Renato revelou que comprou a porção de maconha, com peso de 23,5g (lacre nº 0036611), que foi localizada dentro do seu veículo Kadett, de EVERALDO e lhe pagaria R\$ 40,00 (quarenta reais) quando recebesse o “vale”. Ato contínuo, a equipe policial dividiu-se. Ao aproximarem-se da residência próxima ao local destinado à “reciclagem” manejada por EVERALDO, os policiais visualizaram EVERALDO dispensar uma bolsa preta e, na tentativa de disfarçar, seguiu à residência de seu afilhado Lucas, que o acompanhava. Ambos foram abordados pela equipe policial. EVERALDO afirmou que tinha uma porção de maconha em sua residência, a qual foi localizada em seu quarto, com peso líquido aproximado de 50,6g (lacre nº 0036612), negou ter arremessado algo e admitiu ter fornecido a porção de maconha ao Renato. Com EVERALDO havia R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em dinheiro. A bolsa preta (lacre nº 019770), dispensada por EVERALDO (periciada às fls. 162/164), continha 11 (onze) porções de maconha, embaladas de forma idênticas àquela encontrada com Renato, as quais pesavam 772,41g (lacre nº 0036613). Considerando que o terreno onde ocorreram os fatos era grande e a denúncia prévia relatada que EVERALDO escondia grande quantidade de droga no matagal, foi realizada busca ampla neste local e, com apoio do canil, foram localizados, a aproximadamente vinte metros da casa de EVERALDO, sob folhagens, outro saco preto contendo 04 (quatro) tijolos de maconha, com peso líquido total aproximado de 2.701,78g (lacre nº 0036614), uma faca com resquícios de droga e papel filme (fls. 75 e 162/164). Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, a confirmar prévios informes que indicavam que o denunciado realizava o tráfico de drogas no local dos fatos, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas encontradas seriam destinadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes”. Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 202/206), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 212), o despacho de fls. 224/227, de 29 de julho de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 288/289), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o Dr. Defensor (fls. 288/289), requer a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por absoluta ausência de provas, ou sua desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de usuário e não de um traficante.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados a ré encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 21/26; pelo laudo pericial em objeto de fls. 100/104, que resultou em "PEÇA A - 1 (um) travesseiro, com sua parte posterior de cor preta, e parte anterior na cor bege, com inscrições na cor marrom e preta, usado, em regular estado de conservação, sem marca aparente. PEÇA B - 01 (uma) mala de viagem com quatro rodas, da marca "PARANÁ", confeccionada em material sintético ROSA. RESULTADO: Por meio das análises físico-químicas realizadas no líquido de lavagem obtido da PEÇA A (Travesseiro) e da PEÇA B (Mala), FOI DETECTADA A PRESENÇA DE THC (tetrahydrocannabinol) na PEÇA B, substância listada em Portaria 344/1998 SVS/MS -Lista F2 (Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil); pelo laudo químico toxicológico de fls. 105/107, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0033323 ) Descrição: 01 (um) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais prensado(s) na forma de tijolo(s) e constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos. Massa Bruta e/o Quantidade: 1054,06 grama(s) - mil e cinquenta e quatro gramas e seis centigramas. Massa Líquida: 1005,56 grama(s) - mil e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo químico toxicológico de fls. 113/115, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0033322) Descrição: 05 (cinco) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais prensado(s) na forma de tijolo(s) e constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 5060,51 grama(s) - cinco mil e sessenta gramas e cinquenta e um centigramas. Massa Líquida: 4867,55 grama(s) - quatro mil e oitocentos e sessenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 162/236; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Lucas Felipe Gouveia, é enteado do réu, por isso presta depoimento sem compromisso legal. Disse que está preso por porte ilegal de arma de fogo, desde dia 16/6/2022. Nunca cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que estava trabalhando, momento algum mexem com droga, admite que fuma sim, que são crônicos no uso de droga. Que o Renato chegou no local, deu um pedacinho para ele, fumaram juntos, porque quando ele tem, ele nos fornece e quando a gente tem, fornecemos para ele. Fumaram juntos e Renato foi embora e quando subia rua de sua casa, a viatura o abordou, e entraram dentro de sua casa, acharam uma droga, chamaram o canil e encontraram mais droga para baixo de sua casa que não é de sua propriedade, mas da prefeitura. Disse que a droga não era nossa, mas o policial disse que a droga nos pertencia, mas não era nada nosso. Disse que falar que "era nosso" e "não era nosso", porque foi pego junto com seu padrasto, o Everaldo. Afirma que fumaram juntos a droga, e quando o Renato chegou estávamos trabalhando, e ele foi lá fumar com a gente, os três fumaram juntos. Sabe que Everaldo deu um pedacinho de maconha, porque quando ele tem, ele nos fornece um pedacinho e quando nós temos a gente dá para ele um pedacinho. Quando o Renato saiu a viatura o abordou e entraram para dentro de sua casa. Fizeram buscas mas não encontraram nada. encontrou dentro da propriedade somente o pedacinho que a gente estava fumando. Afirma que encontraram droga nos fundos, na mata da prefeitura, em local público, usaram o canil para localizar a droga. Afirma que tinha a arma de fogo que

apresentou para a polícia, e tinha a arma porque estava sendo ameaçado e comprou para lhe proteger e proteger sua família. Os Policiais não mostraram a droga que foi apreendida na mata. Apresentaram somente no plantão policial.

O PM Marcelo Jacometo, sob o crivo do contraditório declarou que dias antes dos fatos receberam denúncias anônimas informando que o réu estava vendendo droga, no linguajar de rua, "no peso". Foram averiguar essa denúncia, é um tipo de reciclagem, e quando entraram na rua vinham saindo pra rua, pessoa de nome Renato, que vinha tão distraído que chegaram próximo a ele cerca de 5 metro, e quando ele percebeu, arremessou algo para dentro do veículo, onde tinha uma menor, dando para constatar de imediato que se tratava de droga. Já visualizamos dentro da casa, aos fundos, duas pessoas que entraram rápido, contornando a casa. A equipe se dividiu, acompanhou ele e viu quando ele arremessou algo no mato e se dirigiu para a casa dos fundos, que era de um parente, e foram identificados como Everaldo e Lucas. Foram revistados e nada de ilícito foi encontrado, e perguntado se tinha alguma coisa na casa, ele disse que tinha droga e os levou até um cômodo e nos apresentou uma pequena porção de droga. Indagado o que ele tinha arremessado, ele disse que não arremessou nada, mas no local encontraram uma bolsa com porções idênticas a que foi encontrada com o Renato. Foi solicitado o canil, porque o terreno é grande e a denúncia já informava que ele escondia a droga naquele terreno próximo a casa dele, pois é um terreno de fundo de vale, no canto do bairro. Nesse momento, indagou ao Renato quanto a droga, ele disse que pegou com Everaldo e disse que pagaria R\$ 40,00, posteriormente, e como o conhecia a bastante tempo, pegava fiado para pagar no vale. Indagado ao Everaldo, disse que o Renato tinha dito isso, ele então disse que fornecia a Renato, sem fins lucrativos, pois são amigos, e negou que a bolsa era dele. O Canil realizava as buscas, próximo a casa dele tem um chiqueiro, tem uma vegetação fechada ao lado e ao fundo tem uma trilha, onde o cachorro indicou onde foram encontrados os tijolos de maconha e embalagens idênticas as que estavam na sacola. Foi dada voz de prisão e encaminhados à Delegacia de Polícia. Confirma que na residência, no quarto dele foi encontrada uma porção e na sacola foram encontradas porções já fracionadas para venda que ele teria arremessado, com ele nada de ilícito foi encontrado. Quanto a embalagem da droga alienada Renato e dos tabletes que foram encontradas no quintal, era embalada um plástico filme, inclusive foi encontrado um rolo de plástico filme da mesma qualidade junto com a porção dos tijolos maiores, ressaltando que para chegar ao local, era de difícil acesso, apesar de próximo a residência do acusado, era bem fechada o acesso da rua, só dava acesso por detrás do chiqueiro dele, onde foi encontrada a maior quantidade de droga. Havia a residência do afilhado do acusado, à direita, pois a esquerda, não havia mais nada, apenas pastagens e o fundo para mata. Quando chegaram no local, ao abordarem o Renato, viu que saiu do local igual criança, com a droga que havia conseguido e na mão dele, mas ele não tinha percebido a presença da equipe, tanto que chegaram a 5 metro dele e viram quando ele arremessou para dentro do veículo, mas deu para perceber que se tratava de um pedaço de droga, de tanto próximo que chegaram dele, ele estava tão distraído com a situação, e a droga foi localizada dentro do veículo. Afirma que encontraram uma porção de maconha com o Renato, pequena, e nada de ilícito foi encontrado com Everaldo ou Lucas. Foi o próprio Everaldo que indicou o quarto para entrar, indicou onde estava uma porção de droga, não se recorda se estava sobre a cama. Era maconha, pouca quantidade, tendo ele dito que era para consumo próprio. Everaldo também admitiu que teria dado uma porção para o Renato, mas disse que não pegou dinheiro. Afirma que a maior quantidade de droga foi encontrada próximo a casa do réu, não no fundo de vale, ao lado da casa dele, é um terreno baldio onde já começa a vegetação. Não tem rio que passa no local, é somente porque tem o chiqueiro e em volta vai crescendo pés de mamona. Não sabe informar o que é da prefeitura ou propriedade particular. Encontraram a droga com o canil próximo a esquerda próximo ao chiqueiro que pertence ao réu.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a

credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

O réu Everaldo Aparecido Sales Freitas, em seu interrogatório declarou que já foi preso anteriormente. Sobre os fatos disse que confessa os fatos, conhece o Sr Renato que sempre usou droga contigo. Nesse dia ele chegou em sua residência pedindo uma porção de droga para “salva-lo”, e como tinha acaba de fumar dois baseados, deu um pedaço para ele. Quando ele saía, parece que o BAEP vinha subindo pela rua e o abordou, parece que ele jogou a droga, e disse que tinha jogado um baseado e entraram em sua residência perguntando se havia dado algum baseado para o Renato, disse que não, disse que deu apenas um baseado para ele, pois jogam bola

juntos, e quando ele tem, ele nos oferece e quando eu tenho, ofereço a ele. Os policiais perguntaram se havia mais droga na residência, confirmou e disse onde se encontrava, onde foram e encontraram dois baseadinhos e dois cigarros feitos que guardou para fumar mais tarde. Afirma que quando encontraram a droga em seu quarto, fizeram muitas perguntas e disse que tinha apenas aqueles baseados que era para fumar e a droga que deu para o Renato. O Policial disse que chamaria o canil, o respondeu a eles que poderia chamar, que ficassem a vontade para trazer os cães, porque não tinha mais nada em sua casa. Logo depois eles desceram numa área pública, que é da prefeitura, e disseram que acharam essa droga naquele local, mas não viu eles encontrando a droga, pois estava sob custódia em sua casa, juntamente com Renato, seu filho e sua esposa, que acompanhou tudo em sua casa. afirma que os policiais lhe ameaçaram, queriam saber onde tinha mais droga, e tudo o que tinha apresentou para eles. Foi ameaçado pelo Tatu que correu na hora que o Renato foi abordado. Afirma que ficaram dois policiais em sua casa, enquanto ficou algemado com Lucas e Renato no carro dele, outros policiais correram atrás dele, e foram atrás de um tal de Tatu que mora na rua da sua casa e que ele não conseguiram pegar.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, o Lucas, seu enteado, que a tudo presenciou também apresentou justificativas, principalmente quanto a droga apreendida com Renato, dizendo que deu um pedacinho a ele, pois quando ele tem, oferece ao réu e a testemunha Lucas, e quando estes têm oferece a Renato, todavia, essa narrativa não convence, já que um cigarro ou uma pequena porção que se compartilha não pesa quase 25 gramas de maconha, trata-se de uma porção generosa, que é evidente ter comprado do réu, porém, Renato também mentiu quando disse em solo policial, que pagaria R\$ 40,00 quando recebesse o vale. Contudo, parece uma narrativa pronta, orquestrada, contrária a toda a prova dos autos, tentando a todo custo desmerecer o eficiente e notável trabalho da Polícia Militar, especialmente no combate ao tráfico de drogas em nossa cidade e região, vez que seu depoimento foi firme e coeso quando confirmou os fatos como descritos na denúncia.

A narrativa do réu em tentar se livrar da acusação, dizendo que a droga foi localizada num terreno da prefeitura não convence, até porque ele mesmo disse que não viu onde localizaram a droga, num primeiro momento disse que ficou na área de sua casa com Lucas, Renato e sua esposa, depois disse que ficou somente com Lucas e Renato no carro dele.

É bem conveniente imputar aos Policiais Militares, que em todos os casos semelhante, os acusados negam lhes pertencerem, que são apenas usuários crônicos de drogas, mas se esquecem que os cães farejadores da Polícia Militar, tão bem treinados, são capazes de localizar droga em qualquer local, por isso a negativa da localização das drogas, todavia, é bastante comum não terem grande quantidades em suas residências justamente para tentarem burlar o estado flagrantemente, e caso o cão de faro encontre droga fora do terreno ou da propriedade, tentam se eximir da propriedade, portanto, sua narrativa não merece credibilidade, pois, completamente isolada nos autos.

Não é concebível que Policiais Militares que tão bem exercem suas funções imputem falsamente um grave crime a pessoas que sabe inocentes, é uma teoria inconcebível e difícil crer, já que são pessoas investidas em funções públicas de segurança e sabem perfeitamente que imputar um crime grave a um inocente, as sérias consequências que irão levar a pessoa.

Portanto, toda a narrativa apresentada pelo réu é enfraquecida pela robusta prova amealhada nos autos, comprovando sobremaneira a traficância praticada pelo réu em sua residência e local de trabalho, onde se utiliza de um terreno público para esconder a grande parte da droga, que após fracionada e embalada é exposta a venda a usuários. Ademais, é comum vermos no dia a dia do Judiciário fatos semelhantes e narrativas idênticas dos réus no sentido de tentarem se isentarem das drogas encontradas em terrenos baldios, públicos, lugares desabitados, porém, as evidências são suficientes claras para imputar ao réu a propriedade da droga.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (1 porção de maconha pesando 50,6 gramas, 11 porções de maconha pesando 772,41g e mais 4 porções pesando 2.701,78 g da mesma droga), bem como numerário (R\$ 319,00), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Ademais, o desencontro das versões apresentadas pelos réus, que acabam se confundindo entre eles, justamente porque não encontram justificativas para a droga, o dinheiro, os demais objetos usados para embalar drogas, encontradas no imóvel usado ponto de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga, mas também do dinheiro que acabara de receber da venda do entorpecente, num total de R\$ 319,00, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, porções já fracionadas para a venda, além de 4 (quatro) tijolos que ao todo pesaram mais de 3 quilos de maconha, que renderia centenas de porções após fracionadas para a venda.

Além disso, havia mais 2 (dois) rolos de plástico filme usadas para acondicionar droga para a venda a usuários, idênticos aos que a droga já estava embalada para venda. Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde foram surpreendidos.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 54/57, corroborada com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida, decorrente do comércio espúrio de drogas. Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez, nem mesmo quanto ao dinheiro que, embora disse que era fruto de seu trabalho, não conseguiu trazer aos autos provas dessa alegação.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa dos réus e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção do agente.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas -

Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia no celular apreendido de propriedade de Everaldo (fls. 245/261), consta conta de e-mail vinculada - Conta de e-mail vinculada: everaldosales322@gmail.com, número vinculado ao WhatsApp: +551899790-6362(fl. 251), e conversas direcionada ao tráfico de drogas as fl. 253/254, bem como da droga em forma de tijolo, embalada da mesma forma e plástico das que foram apreendidas nos autos, denotando sobremaneira que o réu, pesava e tirava fotos das drogas para enviar ao seus "clientes" demonstrando a quantidade e qualidade, principalmente, porque a denúncia dava informações de que o réu vendia a droga "no peso", ou seja, em grande quantidade, como a que foi apreendida com a testemunha Renato.

Observo que o celular pertence ao réu Everaldo, e possui fotos de drogas, e portanto, evidencia com grande eloquência nos autos a participação direta do réu no comércio espúrio de drogas.

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na residência e principalmente, no terreno adjacente a sua residência e comércio, atrás de um chiqueiro, a fim de despistar as autoridades caso fosse descoberta o seu principal fonte de renda, de onde retirava parte para a venda a terceiro, enquanto a maior parte ficava escondida nos fundos do terreno.

Outro detalhe importante a ser destacado foi o fato de o réu ter alegado que a droga pertence a um tal de "Tatu", porém, diante do relatório da Polícia Civil confeccionado pelo DEIC-2ª DISE de Presidente Prudente, dando conta de dois suspeitos que possuem esse vulgo, porém, ao ser novamente ouvido (fl. 177), Everaldo disse não conhecer nenhum deles, de forma a proteger um comparsa ou que realmente suas alegações foram apenas falaciosas em relação a imputação ao "Tatu", a propriedade das drogas.

De fato, nenhum traficante deixa sua droga longe de seus olhos, vez que o valor investido é de difícil reparação em caso de extravio ou furto dessa droga por terceiros, chega beirar o absurdo a alegação do réu nos autos, porém, trata-se de estratégia da defesa do réu.

No caso dos autos a polícia recebeu várias denúncias com informações que o réu vinha realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais, especialmente a forma como abordaram Renato e com ele encontraram 25 gramas da mesma droga encontrada na casa e nos fundos da propriedade do réu.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na



residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia. Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do

produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.:

169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

"[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]" (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º,

da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, I, são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou